

<제1편 총설.제1장 민사소송.제1절 민사소송의 개관>

I. 서론

1. 민사소송법의 의의와 성격

(1) 민사소송법의 개념

- 민사소송법은 사적 분쟁을 국가의 재판권에 의해 강제적으로 해결하기 위한 절차를 규정한 법률이다. 이는 실체법인 민법이나 상법의 권리를 현실적으로 실현하기 위한 도구적 역할을 수행한다.

(2) 공법적 성격

- 민사소송법은 사법상의 권리관계를 다루는 소송을 규율하지만, 국가 기관인 법원이 관여하는 절차를 다루므로 공법에 해당한다. 당사자 간의 합의보다 법에 정해진 절차를 중시하는 강행규정적 성격이 강하다.

2. 법원의 역할과 민사 재판

(1) 사법권의 행사

- 법원은 독립된 지위에서 헌법과 법률에 의해 양 당사자의 주장을 듣고 법적 결론을 도출한다. 이는 법질서의 최종적 보루로서 기능을 수행하는 것이다.

(2) 분쟁의 종국적 해결

- 재판은 확정판결을 통해 분쟁을 영구적으로 종결시키며, 이후 동일한 사건으로 다시 다툴 수 없도록 하는 법적 안정성을 제공한다.

II. 총설

1. 민사소송의 목적과 이상

(1) 민사소송의 목적

① 사권의 보호

- 민사소송은 사적 분쟁을 국가의 재판권에 의해 강제적으로 해결함으로써 개인의 사법상 권리를 실현하는 것을 일차적 목적으로 한다.

② 법질서의 유지

- 개별 분쟁 해결을 통해 궁극적으로는 사회 전체의 사법 질서를 안정시키고 법치주의를 공고히 하는 공익적 성격을 갖는다.

(2) 민사소송의 이상

① 적정과 공평

- 재판은 실체적 진실에 부합하는 적정한 판단이어야 하며, 양 당사자에게 동등한 기회를 부여하는 절차적 공평을 기해야 한다.

② 신속과 경제

- 지연된 정의는 정의가 아니라는 원칙하에 가급적 빠른 시간 내에 최소한의 비용으로 분쟁을 종결하는 효율성을 추구한다.

2. 신의성실의 원칙

(1) 의의 및 적용범위

① 신의칙의 의의

- 소송 당사자와 소송 관계인은 신의에 따라 성실하게 소송을 수행해야 한다는 원칙으로, 소송상 권능의 행사를 제한하는 구체적 기준이 된다.

② 적용대상

- 당사자뿐만 아니라 법원의 절차 운영에도 적용되며, 소송 전반에 걸쳐 공정성을 담보하는 역할을 한다.

(2) 신의칙의 발현형태

① 부당한 소송상태의 창출 금지

- 부정한 수단으로 유리한 소송 조건을 인위적으로 만들어내는 행위는 허용되지 않는다.

② 모순거동의 금지

- 자신의 이전 행위와 모순되는 소송 행위를 하여 상대방의 신뢰를 저버리는 행위는 금지된다.

3. 민사소송법의 적용범위

(1) 인적 적용범위

① 일반적 원칙

- 대한민국의 재판권은 영토 내의 모든 사람에게 미치는 것이 원칙이다.

② 예외적 제한

- 외국 원수나 외교관 등 국제법상 치외법권을 누리는 자에게는 대한민국 재판권이 미치지 않는다.

(2) 시간적 적용범위

① 신법 우선의 원칙

- 소송 진행 중 법이 개정되면 원칙적으로 신법을 적용하나, 구법 하에서 이미 완료된 절차의 효력은 유지된다.

② 소송절차의 안정

- 진행 중인 절차의 혼란을 방지하기 위해 개정법 부칙을 통해 경과 조치를 두는 것이 일반적이다.

III. 소송의 주체

1. 법원

(1) 관할

① 법정관할과 재정관할

- 법률에 의해 직접 정해진 관할을 법정관할이라 하며, 상급법원의 결정으로 정해지는 것을 재정관할이라 한다.

② 거동관할

- 당사자의 합의에 의한 합의관할과 피고의 응소로 발생하는 변론관할이 이에 해당한다.

(2) 제척·기피·회피

① 제척

- 제척은 법관이 사건과 특수한 관계가 있어 법률상 당연히 직무 집행에서 배제되는 제도이다.

② 기피 및 회피

- 공정한 재판을 기대하기 어려운 경우 당사자의 신청으로 법관을 배제하는 것이 기피이며, 법관 스스로 물러나는 것이 회피이다.

2. 당사자

(1) 당사자의 확정 및 능력

① 당사자 확정

- 소장에 기재된 표시를 기준으로 누가 원고와 피고인지를 결정하며, 표시가 잘못된 경우 정정 절차를 거친다.

② 당사자능력과 소송능력

- 소송의 주체가 될 수 있는 일반적 능력을 당사자능력이라 하고, 유효하게 소송 행위를 할 수 있는 지능적 능력을 소송능력이라 한다.

(2) 당사자적격 및 소송대리

① 당사자적격

- 특정 소송물에 대하여 원고로서 청구하거나 피고로서 판결을 받을 수 있는 구체적인 권능이다.

② 소송대리인

- 미성년자 등을 위한 법정대리인과 본인의 수권에 의한 임의대리인으로 구분된다.

IV. 제1심의 소송절차

1. 소송의 개시

(1) 소 제기의 효과

① 소송계속

- 소장이 피고에게 송달되면 사건이 특정 법원의 심판 대상이 된 상태인 소송계속이 발생한다.

② 중복소제기의 금지

- 이미 진행 중인 사건과 동일한 소를 다시 제기하는 것은 판결의 모순 방지를 위해 금지된다.

(2) 실체법상 효과

① 시효중단

- 소 제기는 민법상 소멸시효를 중단시키는 강력한 효과를 발생시킨다.

② 기간준수

- 법률상 정해진 제소 기간을 지키는 효과가 있어 권리 소멸을 방지한다.

2. 변론의 원칙

(1) 처분권주의

① 의의

- 소송의 개시, 심판 범위의 결정, 소송의 종료를 당사자의 의사에 맡기는 원칙이다.

② 내용

- 법원은 당사자가 신청하지 않은 사항에 대해 판결할 수 없으며, 청구 범위를 초과할 수도 없다.

(2) 변론주의

① 사실의 주장책임

- 판결의 기초가 되는 주요 사실은 당사자가 주장해야 하며, 법원이 임의로 탐지할 수 없다.

② 자백의 구속력

- 당사자 사이에 다툼이 없는 사실은 증거조사 없이 그대로 판결의 기초로 삼아야 한다.

3. 증거조사

(1) 입증책임

① 입증책임의 분배

- 사실의 존부가 불명확할 때 불이익을 받는 당사자의 부담을 의미하며, 통상 권리 발생 요건 사실을 주장하는 자가 부담한다.

② 입증책임의 완화

- 증거 편재 현상을 해결하기 위해 일표적 증명이나 법률상 추정 등을 통해 입증의 곤란을 해소한다.

(2) 증거조사 방법

① 서증과 증인신문

- 문서의 내용을 조사하는 서증과 사람의 진술을 듣는 증인신문이 대표적인 증거조사 방법이다.

② 검증과 감정

- 법관이 직접 사물의 상태를 확인하는 검증과 전문가의 지식을 빌리는 감정이 활용된다.

V. 소송의 종료

1. 당사자의 의사에 의한 종료

(1) 소의 취하

① 취하의 요건

- 원고가 소를 철회하는 행위로, 피고가 본안 변론을 한 후에는 피고의 동의가 필요하다.

② 효과

- 소송은 소급적으로 소멸하며, 종국판결 선고 후 취하 시 재소금지의 원칙이 적용된다.

(2) 청구의 포기·인낙 및 화해

① 포기 및 인낙

- 원고가 청구권을 포기하는 행위를 포기, 피고가 이를 수용하는 행위를 인낙이라고 하며, 조서 기재 시 확정판결과 동일한 효력을 갖는다.

② 재판상 화해

- 소송 중 양 당사자가 합의에 도달하여 분쟁을 종결짓는 절차이다.

2. 종국판결에 의한 종료

(1) 판결의 효력

① 기판력

- 기판력은 확정된 판결의 내용이 후행 소송을 구속하여 동일한 쟁점으로 다시 다투지 못하게 하는 힘이다.

② 집행력과 형성력

- 판결 내용을 강제적으로 실현할 수 있는 힘인 집행력과 법률관계를 직접 변동시키는 형성력이 발생한다.

(2) 기판력의 범위

① 주관적 범위

- 판결의 효력은 원칙적으로 소송 당사자에게만 미치며 제3자에게는 미치지 않는 것이 원칙이다.

② 객관적 범위

- 판결문의 주문에 나타난 판단에만 발생하며, 판결 이유 중의 판단에는 발생하지 않는다.

Ⅴ. 병합소송 및 소송참가

1. 병합소송

(1) 객관적 병합

① 단순병합

- 여러 청구를 병렬적으로 세워 모두에 대한 심판을 구하는 형태이다.

② 예비적 병합

- 주된 청구가 인용되지 않을 경우를 대비하여 차순위 청구를 하는 방식이다.

(2) 주관적 병합

① 통상 공동소송

- 여러 사람이 함께 소송하되 각자의 소송 행위가 서로에게 영향을 주지 않는 독립 원칙이 적용된다.

② 필수적 공동소송

- 소송물의 성질상 합일적으로 확정되어야 하여 전원이 함께 소송을 수행해야 하는 형태이다.

2. 소송참가

(1) 보조참가

① 의의

- 소송 결과에 이해관계가 있는 제3자가 어느 한쪽을 돕기 위해 참여하는 제도이다.

② 효력

- 참가인은 당사자를 지원하는 행위를 할 수 있으나 피참가인에게 불리한 행위는 제한된다.

(2) 독립당사자참가

① 의의

- 제3자가 소송 당사자 양쪽 또는 한쪽을 상대로 자신의 권리를 주장하며 소송에 개입하는 방식이다.

② 요건

- 기존 소송의 결과에 의해 자신의 권리가 침해될 우려가 있거나 소송물이 자신의 권리임을 주장할 때 가능하다.

Ⅵ. 상소 및 재심절차

1. 항소심 절차

(1) 항소의 제기

① 기간 및 방법

- 1심 판결 송달 후 2주 이내에 항소장을 제출해야 하며, 불복의 범위를 명시해야 한다.

② 부대항소

- 상대방이 제기한 항소 절차 내에서 자신의 불복을 신청하는 제도로 항소권 소멸 후에도 가능하다.

(2) 항소심의 심리

① 속심제

- 1심의 심리 상태를 바탕으로 항소심에서 새로운 자료를 추가하여 심리하는 방식을 취한다.

② 불이익변경금지

- 항소인에게 1심 판결보다 불리한 결과를 초과하여 판결할 수 없다는 원칙이다.

2. 상고 및 재심

(1) 상고심

① 상고이유

- 2심 판결에 법령 위반이 있는 경우에만 대법원에 상고할 수 있으며 사실관계는 다를 수 없다.

② 심리불속행

- 상고이유가 법정 사유에 해당하지 않으면 더 이상 심리하지 않고 기각하는 제도이다.

(2) 재심절차

① 재심사유

- 확정된 판결에 중대한 절차적 하자나 증거 위조 등의 사유가 있는 경우 제기할 수 있다.

② 제척기간

- 재심 사유를 안 날로부터 30일, 판결 확정 후 5년 이내에 제기해야 하는 엄격한 기간 제한이 있다.

Ⅶ. 결 론

- 민사소송법은 사적 분쟁의 공정한 해결을 위한 절차법으로서 적정과 공평, 신속과 경제라는 가치를 균형 있게 추구한다. 법원과 당사자라는 소송 주체의 엄격한 역할 분담과 신의성실의 원칙을 바탕으로, 소의 제기부터 판결의 확정 및 비상 구제 수단인 재심에 이르기까지 정밀한 체계를 갖추고 있다. 본 개론에서 다룬 관할, 당사자 확정, 변론주의 및 처분권주의, 기판력의 범위 등은 실질적인 권리 구제를 보장하는 핵심적 기둥이다. 특히 현대 소송에서

는 복잡해지는 분쟁 양상에 대응하기 위해 병합 소송과 소송 참가 등의 제도가 중요하게 작용하며, 상소 제도를 통해 재판의 오류를 시정할 기회를 보장한다. 결론적으로 민사소송법은 법치주의 하에서 개인의 권리를 실현하고 사회적 정의를 확립하는 필수적인 제도적 장치라 할 수 있다.